



デジタル時代に 対応する刑事訴訟法

中京大学准教授
山田峻悠
YAMADA Takaharu

はじめに

科学技術の発展は、我々の生活に様々な恩恵をもたらしてくれるが、刑事法の分野からみると、負の側面もある。犯罪者も当然、新たな科学技術に目を付け、これまでになかった新たな手法で犯罪を実行しており、捜査機関もこうした新たな手法に対応していかなければならない。例えば、昨年、匿名・流動型犯罪グループによる犯罪の家宅捜索中に捜査官が被疑者に暴行を加え、特別公務員暴行陵虐罪で訴追された事件が発生した¹⁾。この事件で捜査官が暴行を加えてしまった理由は、発見されたスマートフォンのロック解除のために必要なパスワードを被疑者が教えなかったためであるとされる。従来、証拠品は文書などの有体物であったが、情報技術の発展に伴い、これまで紙媒体で保存されてきたものが、コンピュータやスマートフォンなどに電子データとして保管されるようになってきている。このように電子データで存在する証拠に対して捜査を行う上で重大な障壁となっているのが、電子データが暗号化された状態で保存されている点である。暗号化技術の発展に伴い、暗号化された電子データをパス

ワード等の暗号化キーなしに復号することは困難である。それゆえ、前述した事件のように、暗号化されたデータの復号に電子データの所持者が任意に協力しない場合、捜査機関は非常に困難な立場に置かれることになるのである。

本稿は、このような暗号化された情報の取得という新たに生じた問題を素材にして、刑事手続を規律する基本原理の考え方を示してみたいと思う²⁾。

我が国の刑事手続を 規律する基本原理

1. 刑事訴訟法の意義・目的³⁾

新聞やテレビなどの報道をみれば、日々様々な犯罪が生じている。このように犯罪が発生した場合に、捜査機関が犯人の発見や証拠の収集を行い、裁判で有罪であると証明できるだけの証拠が集まったと判断すれば、検察官がその者を起訴し、その起訴された者（被告人）が有罪であるとの証明を検察官ができていないかを、裁判官が被告人側からの反証を聴いた上で判断し、適正な処罰を行う。このような犯罪の発生から裁判が確定するまでの一連の過程を刑事手続という。

刑事手続の意義を考える前提として、まず、現代社会においては犯罪が生じた場合に誰かが必ず犯罪を目撃しているとか、重要な事実を知っている人が簡単に見つかるということはなく、捜査機関が証拠の収集を強制力を用いて行わなければ、事案の解明ができないことがほとんどであることを理解しなければならない。犯罪が行われても犯人を処罰できなければ、刑法で犯罪と刑罰を定め、応報や犯罪の抑止（一般予防）、犯罪者の更生（特別予防）を図ろうとしても無意味なものとなる。他方で、犯人処罰のためならば手段を選ばず何をしてしまってもかまわないということになれば、我々国民の自由やプライバシーなどは踏みにじられ、刑事手続の執行それ自体が犯罪に匹敵するような脅威を我々に及ぼすことになる。そこで、刑事訴訟法（以下

1) 「捜索中の暴行認める 地裁初判 大阪府警の2警官」読売新聞全国版2025年10月16日付朝刊28面。

2) なお、より理解を深めるために、デジタル時代の犯罪捜査の課題を「憲法」の視点から論じる本特集Ⅰ(6

頁[小西葉子])と対比しながら読むことを推奨する。

3) 椎橋隆幸編著『よくわかる刑事訴訟法〔第3版〕』(ミネルヴァ書房、2022年)4-5頁[柳川重規]。

「刑訴法」と表記する) 1 条に定められているように、刑事手続においては、公共の福祉と基本的人権保障との均衡を図りつつ、事案の真相を明らかにすることが求められる。これが刑訴法の目的である。

我が国の憲法は、アメリカ合衆国憲法に倣い、刑事手続において個人に保障される権利を 31 条から 40 条に定めている。また、人権保障の総則的な規定である憲法 13 条では、これらの権利保障も絶対的なものではなく、公共の福祉による制約を受けるとしている。そして、これらの憲法上の権利を具体的に実現するために刑訴法を中心に、刑事訴訟規則、警察官職務執行法、通信傍受法等の様々な関連規定が定められている。刑事手続は、このように個人の人権保障と事案解明の必要性との均衡を図るという目的をいかに実現するのが問題とされるのであり、刑訴法を学習する上では、このような「対立利益の調整」を憲法・刑訴法がどのように行っているのかを理解することが重要となる。また、刑事手続は、捜査・起訴・公判・上訴・再審といった各段階で対立利益が異なり、段階に応じた検討を行うことが肝要となる。

2. 犯罪捜査を規律する基本原理

さて、犯人を発見し、証拠を収集する活動である捜査は、個人の同意に基づく権利侵害性の低いものから、個人の意思に反しても行われる権利侵害性の高いものまで様々なものがある。我が国はこのような多様な捜査活動を規律するに当たって、個人の権利・利益に大きな制約を加える処分を強制処分、それ以外を任意処分と区分してそれぞれ要件を設定している。このうち、強制処分に関しては、個人の自由や権利に大きな制約を課す捜査活動であるため、強制処分法定主義(刑訴 197 条 1 項ただし書)がとられ、刑訴法に具体的な根拠規定がなければ行えないとされている。

我が国の刑訴法では、強制処分として搜索、差押え、検証、鑑定、通信傍受を規定しており、これら強制処分を規律する基本原理は憲法 35 条に規定されている⁴⁾。同条 1 項が、「住

居、書類及び所持品」を保護対象の例に挙げていることから、憲法 35 条は個人のプライバシーの権利を保障していると解釈されており、そして、このプライバシーの権利に対しても、搜索・押収を行う①正当な理由(犯罪が行われたと疑うに足りる相当な理由)があり、②その被疑事実と関連性を有する物に押収対象が限定され、③そうした物が存在する蓋然性の高い領域に搜索場所が限定されていれば(実体要件)、搜索・押収により干渉することが許されるとしている。さらに、これら実体要件の充足を確認し、実体要件のごまかしを防ぐために、原則令状に基づいて行わなければならないとされ、搜索・押収に先立って、捜査機関から独立した裁判官の審査を受けることを求めている(令状要件)。このように、憲法 35 条は、証拠の収集・保全において対立する利益の調整の仕方を示しているのである⁵⁾。

3. 新たな事態への対応の仕方

後述する情報の取得活動のように、上記のような対立利益の調整により規定された従来の捜査手法ではうまく対応できない、新たな事態が生じた場合に、それに対応するために捜査機関が開発した捜査手法をどのように規律するべきか。この点に関しては、アメリカのように、それが憲法に反しないかを裁判所が判断し、憲法上許容されるのであれば適法とし、議会がより細かな規制、あるいはより厳格な規制が必要であると考えた場合には、事後に法律を制定して包括的な規制を加えるという方法がある⁶⁾。これに対して、我が国では、上述のように、強制処分法定主義が、刑訴法上の大原則であるとして、新たな捜査手法が強制処分に当たる場合には、先に法律を制定しなければこれを許さないとの対応の仕方をとっている。

もっとも、個人の権利を制約する処分がすべて強制処分だとすると、それらのすべてに刑訴法上の根拠規定がなければならなくなり、法律の制定には時間がかかるので、効果的な捜査の遂行が大きく阻害される。そこで、我が国の判例・有力学説は、強制処分を日常用語として用

4) 椎橋編著・前掲注 3) 48-49 頁 [柳川]。

5) 椎橋隆幸編『プライマリー刑事訴訟法(第 6 版)』(不磨書房, 2017 年) 99-100 頁。

6) アメリカの捜査に関する判例の発展については、渥美東洋『捜査の原理』(有斐閣, 1979 年)等を参照。

いられる意味とは異なり、重大な権利・利益に対して実質的な制約（強い干渉）を加えるものに限定して解釈すること⁷⁾により、強制処分法定主義の適用範囲を制限し、捜査の必要にも配慮するという現実的な対応をとっている。



情報の取得活動とその問題点

1. 情報の取得活動とその限界

我が国の刑訴法が制定された当時、証拠となるのはもっぱら凶器や帳簿などの「有体物」であり、電子データのような「無体物」の取得活動は想定されていなかった。しかしながら、情報技術の発展とともにコンピュータが普及していくと、証拠となるものが電子データとして保存されるようになり、捜査機関もこれに対応していく必要に迫られた。この点、我が国では、強制処分法定主義の下、強制処分とされる活動は予め刑訴法に定められた規定に基づく必要があるが、我が国の刑訴法は、基本的には証拠が有体物であることを前提に定められていた。そこで、無体物である電子データ自体を押収の対象とできないことから、その電子データが保存されているコンピュータ本体やサーバ、ハードディスク等の有体物（以下「電磁的記録媒体」という）を差し押さえるという手法がとられた⁸⁾。また、通信傍受などの新たな情報の取得行為について、既存の「検証」⁹⁾の概念に含ませることでこれを行うという方法がとられたこともあった¹⁰⁾。しかし、電磁的記録媒体には、従来の捜査活動の対象となってきた日記や帳簿などと比べて、圧倒的に膨大な量の、様々なデータが保存されており、その中には被疑事実とは全く関係のない個人的なデータが含まれていることもある。したがって、電磁的記録媒体自体を差し押さえることは個人のプライバシーの権利に大きく干渉しうるものであった。また、こ

のような個人のプライバシーへの干渉を回避するため、差押えを行う際に、現場で差押え対象物であるか否かを判別することも考えられるが、この手法は、膨大な情報を確認しなければならない捜査機関にとっても、それに対応しその間業務等を停止しなければならない被処分者にとっても大きな負担となる。さらに、情報の取得活動を既存の強制処分に照らして行うことの限界も示されるようになっていた。被処分者の位置情報を取得する装着型 GPS 捜査という新たな捜査手法に関して、最高裁は、既存の「検証」と類似する性質があるとしつつも、既存の強制処分には包含できないとし、立法による解決を求めた¹¹⁾。このように、既存の「検証」の概念を拡大し、情報取得の規律を行おうとする法解釈に対して、近年、最高裁は否定的な態度をとっている。

以上のように、「有体物」を対象とした刑訴法で「無体物」である情報を取得することには限界があり、強制処分法定主義の下で情報の取得に対応するための新たな立法上の対応が求められることになったのである。

2. 情報の取得活動に対する立法的な対応

(1) 2011年の法改正の概要

上述したような新たな法整備を行う必要性から、2011年「情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律」が制定され、①電磁的記録に係る記録媒体の差押えの執行方法、②記録命令付差押え、③リモートアクセス捜査、④被処分者への協力要請、⑤保全要請という新たな手続が導入され、立法的な対応がなされた。このうち、本稿との関連で重要な①、②、④について概観していこう。

①に関して、差し押さえるべきものが電磁的記録である場合、差押者もしくは被差押者がほかの記録媒体に電磁的記録を複写等した上で差

7) 最決昭和51・3・16刑集30巻2号187頁、最大判平成29・3・15刑集71巻3号13頁。また、井上正仁『強制捜査と任意捜査〔新版〕』（有斐閣、2014年）2-32頁を参照。

8) 最決平成10・5・1刑集52巻4号275頁。

9) 検証は、犯行現場の状況など、法廷にそのままの形で提出できない証拠を、事実認定者が証拠として利用できるように、捜査官の五官の作用（視覚、聴覚、嗅覚、触覚、味覚）を通じて、書面・文書・図画・写真等を用いて

証拠の示す状態を正確に保全する活動を指す。無体物である情報を五官の作用を通じて認識・記録する行為は検証と解しうる。

10) 例えば、電話傍受に関して最決平成11・12・16刑集53巻9号1327頁を参照。

11) 前掲注7)最大判平成29・3・15。同判決の意義に関して、柳川重規「位置情報とプライバシー」法学新報125巻11=12号（2019年）605頁等を参照。

し押さえることができるとされた（刑訴 110 条の 2・222 条 1 項）。②に関して、裁判所または捜査機関は、電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、または印刷させた上、当該記録媒体等を差し押さえることができるとされた（刑訴 99 条の 2・218 条 1 項）。④に関して、差し押さえるべきものが電磁的記録である場合、捜査差押え許可状を執行する者は、被処分者に対して、コンピュータの操作等の必要な協力を求めることができるとされた（刑訴 111 条の 2・222 条 1 項）。これらの方策は、有体物を前提とする既存の考え方を維持しつつも、実質的には電磁的記録それ自体を差し押さえることを認めるものであり、その意味で犯罪に無関係なものを含め包括的に記録媒体を差し押さえる従来の捜査方法の問題を一応解決したものであると評価されている¹²⁾。また、これらの方策は、電磁的記録媒体自体の差押えをしないことで被処分者の負担の軽減を図る側面があり、被処分者が記録命令に進んで応じることが想定されている。被処分者が応じなかった場合には、罰則はないが、記録媒体自体の差押えといった手続に移行することになるため、その意味で事実上の強制力が認められ、その実効性が担保されていた¹³⁾。

(2) 2025年の法改正の概要¹⁴⁾

2011 年の法改正で導入された手法でも、結局従来の捜査法と同様に有体物を対象とする前提をとっていたため、①捜査機関が記録媒体を対面で差し押さえる必要があり、その実施にあたって被処分者のもとを訪ねる捜査機関及びそれに対応する被処分者の双方にとって相当な負担が依然として生じている、②クラウド上のデータなど、差し押さえるべき電磁的記録の所在が判明せず、差押えができない場合がある等の問題が残されていた¹⁵⁾。このような問題に対処するために、2025 年に「情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を

改正する法律」が制定され、2011 年改正で導入された記録命令付差押えの規定が削除される代わりに、電磁的記録提供命令の制度が新たに創設されることになった。

電磁的記録提供命令の下で、裁判官は、電磁的記録の保管者等に対して、必要な電磁的記録を、記録媒体に記録させて提供する、もしくはインターネット回線を通じて命令をする者の記録媒体に移転するように命令することができるようになった（改正刑訴 102 条の 2）。同命令は、これまでの方法とは異なり、無体物である電磁的記録それ自体を対象としている点に特色があり、したがって、電磁的記録が保存されている記録媒体を特定する必要がなくなった¹⁶⁾。電磁的記録提供命令は、提供させるべき電磁的記録及び提供の方法を指定してするものとされる。また、捜査機関も裁判官の発する令状により電磁的記録提供命令をすることができ、令状には被疑者の氏名、罪名、提供すべき電磁的記録、提供方法等を記載しなければならない（改正刑訴 218 条 1 項・219 条 1 項）。

正当な理由がなく、提供命令に従わなかったときは 1 年以下の拘禁刑もしくは 300 万円以下の罰金に処されることになる（改正刑訴 124 条の 2 第 1 項・222 条の 2 第 1 項）。また、法人の代表者等が、法人の業務に係り、提供命令に従わなかった場合は、行為者のほか、その法人等にも罰金が科されることになる（改正刑訴 124 条の 2 第 2 項・222 条の 2 第 2 項）。



暗号化された情報の取得と理論的課題

1. 復号した情報を取得するための方策

暗号化された情報を取得する方法として、記録媒体の差押えもしくは他の電子媒体に電子データの複写等を行い差し押さえる際に、刑訴法 111 条の 2・222 条 1 項に基づき、被処分者に暗号化された電磁的記録を復号するように協

12) 椎橋編・前掲注 5) 105 頁。

13) 中野日義則＝四方光編著『サイバー犯罪対策』（成文堂，2021 年）150-156 頁〔中村真利子〕。

14) 2025 年改正に関しては、中村竜太郎ほか「情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律について」RESEARCH BUREAU 論究 22 号

（2025 年）243 頁。とりわけ、電磁的記録提供命令に関しては、成瀬剛ほか「〔鼎談〕電磁的記録提供命令の創設」ジュリ 1614 号（2025 年）ii-v 頁、66-82 頁等を参照。

15) 成瀬ほか・前掲注 14) iv 頁。

16) 成瀬ほか・前掲注 14) iv 頁。

力要請を行うことが考えられる。仮に協力を得られなかった場合は、差押え等の必要な処分（刑訴110条・222条1項）として、捜査機関自身もしくは専門的知見を有する補助者によって復号を行う措置をとることが考えられるが、高度化する暗号化技術を踏まえると復号することが困難あるいは不可能な場合も存在するであろう。

そこで、新設される電磁的記録提供命令が、暗号化された情報の取得方法として重要な方法となりうる。同命令の下では、電磁的記録の保管者等に対して、暗号化された電磁的記録を復号した状態にして他の記録媒体に記録させて提供するように命じることができる。電磁的記録提供命令には、罰則による強い強制力が付与されており、協力的ではない被処分者からも復号した電磁的記録を取得することをより期待することができるだろう。

一方で、このように罰則により協力を行うような法的に義務付ける手法をとる場合には、憲法38条1項に保障される自己負罪拒否特権との関連が問題となる。上述したように、電磁的記録の取得を行うために様々な立法措置がなされてきたが、捜査の必要性があるからといって無制約にそれが許容されるわけではない。裁判所に違憲審査権が与えられている我が国の憲法の下では、憲法の保障する基本権を侵害する立法は無効とされるのであり、憲法上の基本権との調和を図る必要がある。

2. 自己負罪拒否特権保障との関係

(1) 自己負罪拒否特権の対象

憲法38条1項は自己負罪拒否特権¹⁷⁾を保障している。すなわち、のちに刑事責任を問われ

る事項について、刑罰などの制裁をもって供述するように強要される（法的義務付け）ことのない権利が我が国では保障されており、法的義務付けにより得られた供述はその供述者の刑事裁判で利用することが禁止されることになる。この自己負罪拒否特権による保護を受ける対象は「自己に不利益な供述」のみであり、この「供述」の意義については争いがある。供述というと口頭での発言のみを指すように文理解釈できるが、学説では、「供述」を「意思伝達の性格をもった行為」をも含むものと解し、口頭での発言のみならず、供述と同様の性質を有する行為に関しても自己負罪拒否特権の保障は及ぶとする見解が多数を占めてきた¹⁸⁾。この点、判例は、強制採尿¹⁹⁾や呼気検査²⁰⁾で採取される尿や呼気等の非供述証拠には自己負罪拒否特権保障は及ばないという立場を示してきたが、学説のいう供述と同様の行為にもその保障が及ぶのかという論点に関しては、必ずしも判断は明らかにされていない。

(2) 復号した情報の提供を強要することと自己負罪拒否特権保障²¹⁾との関連について

電磁的記録提供命令との関連を考察してみよう。まず、自己負罪拒否特権の対象を「口頭での発言」に限定する見解に立てば、電磁的記録提供命令は既に存在する電磁的記録を提供するように求めるにすぎないことになる。また、暗号化の解除に関してもパスワード等を供述するように義務付けることは自己負罪拒否特権の保障に抵触することになりうるが、パスワード等を入力させる行為自体には自己負罪拒否特権保障は及ばないことになる。したがって、この立場からは、電磁的記録提供命令は自己負罪拒否特権保障に抵触するものではないと考えること

17) 我が国では、憲法38条1項により、供述するか否かを選択できる包括的な黙秘権が保障されていると説明されることもあるが、黙秘権は、取調べ時の抑圧的な雰囲気等により供述を事実上強制されることから保護を与えるものに対して、自己負罪拒否特権は、法的義務付けからの保護を与えるものであるとして、両者を峻別して説明する理解もある（椎橋隆幸ほか『ポイントレクチャー刑事訴訟法』〔有斐閣、2018年〕133-134頁）。本稿は後者の考え方に従い、自己負罪拒否特権の問題として検討していく。

18) 例えば、椎橋隆幸『刑事訴訟法の理論的展開』（信山社、2010年）157頁等を参照。

19) 最決昭和55・10・23刑集34巻5号300頁。

20) 最判平成9・1・30刑集51巻1号335頁。

21) ロック解除の強要と自己負罪拒否特権保障の関係

については、丸橋昌太郎「暗号解除に関する規律について」『日高義博先生古稀祝賀論文集(下)』（成文堂、2018年）393頁、山田峻悠「自己負罪拒否特権の『対象』に関する検討(一)(二・完)」東京都立大学法学会雑誌62巻1号(2021年)447頁、62巻2号(2022年)275頁、梶悠輝「デジタル時代のアメリカ自己負罪拒否特権」同志社法学74巻8号(2023年)41頁、安井哲章「捜査機関が適法に差し押さえたスマートフォンのロック解除に伴う法的問題」研修903号(2023年)3頁、朝村太一「自己負罪拒否行為を法的に義務付ける捜査処分に対する憲法上の規律(一)(二)(三)」法協141巻4号247頁、141巻7号505頁（いずれも2024年）、142巻8号(2025年)837頁、大角洋平『黙秘権の機能的分析』（日本評論社、2025年）250-251頁を参照。

になるだろう²²⁾。

一方で、供述と同様の性質を有する行為にも自己負罪拒否特権保障が及ぶとする見解からはどのように考えられるだろうか。この点、暗号化を解除して電磁的記録の提供を義務付けることは、「義務付けの対象となる電磁的記録が存在すること」、「義務付けの対象となる電磁的記録を対象者が所持していること」、「暗号化された電磁的記録にアクセスでき、復号できること」等の自己に不利益な事実を黙示的に認めるように義務付けるものと捉えることもできる。このような考えを前提とすると、この立場からは、電磁的記録提供命令は供述と同じように負罪情報の提供を義務付けるものであり、自己負罪拒否特権保障に抵触しうることになるのである²³⁾。

このように、たとえ国会での審議を経て新たに導入された制度であったとしても、憲法に規定される刑事手続上の基本権を侵害すると考える余地が依然として残されているのである。自己負罪拒否特権の対象をいかに捉えるべきか、

また、自己負罪拒否特権保障に抵触しうる場合でも自己負罪拒否特権侵害となるのを回避するために依拠できる手段・理論がないのかといった点はさらに検討していかなければならない²⁴⁾。



おわりに

以上、刑事手続に関する基本原理に照らし、暗号化された情報の取得という新たな問題にいかに対応してきたのかを概観してきた。本稿で検討してきたように、科学的技術の発展とともに、新たな手法の犯罪が生じ、それに対抗できるように捜査機関も新たな捜査手法を取り入れる必要がある。一方で、そのような手法が憲法上の原理に反していないことが求められる。このように刑事手続の分野では、個人の人權保障と事実解明の必要性との均衡を図りながら、いかに捜査手法の適正さを保っていくのが問われることになるのである。

(やまだ・たかはる) ㊦

22) 中村ほか・前掲注 14)251-252 頁。

23) もっとも、この立場に立ったとしても、電磁的記録提供命令が自己負罪拒否特権侵害に至らない場合があるとする余地は理論上ありうる。法制審議会刑事法（情報通信技術関係）部会第 10 回会議事録 26-28 頁〔成瀬剛発言〕。

24) 電磁的記録提供命令に関しては、自己負罪拒否特権以外にも、被疑事実と関連しない膨大な個人情報が採取されうる点でプライバシー侵害の懸念が示されているなど、他にも検討すべき課題が残っている。成瀬ほか・前掲注 14)66 頁以下。